

1512301-31.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Eduardo Balbone Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/09/2022

... tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1512301-31.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1512301-31.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DOS SANTOS PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Eduardo Balbone Costa

Vistos.

Narra a denúncia que, "na manhã de 22 de maio de 2022, por volta das 6h33min, na Rua Copenhague nº 116, Guaianases, nesta Cidade e Comarca de São Paulo, TIAGO DOS SANTOS PEREIRA, qualificado a fls. 18 e 21, foi surpreendido trazendo consigo, para o tráfico de drogas, nas imediações de estabelecimento social e beneficente onde se realizam serviços de reinserção social, 246 porções contendo 103,8g da substância "cocaína" em pó e 49 porções contendo 43,4g da substância "tetrahydrocannabinol", popularmente conhecida como "maconha", sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar", pelo que foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/06.

Recebida a denúncia, o réu foi citado.

Após defesa preliminar, ratificou-se o recebimento do libelo.

Em audiência de instrução, ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes e o réu foi interrogado.

O laudo toxicológico foi juntado.

Em alegações finais, postulou o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, com base na prova dos autos.

A defesa, por sua vez, pugnou pela nulidade da apreensão das drogas, realizada por Guardas Civis Metropolitanos e, no mérito, requereu a absolvição, reputando frágeis as provas dos autos e, ainda, subsidiariamente, a mitigação dos rigores da pena. É o relatório do essencial.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do crime encontra indícios diante do auto de apreensão, noticiando a apreensão dos tóxicos. Outrossim, a natureza entorpecente ilícita das substâncias apreendidas foi regularmente ratificada pelo laudo toxicológico definitivo.

Ocorre que há ilegalidade na apreensão das drogas, realizada por Guardas Civis Metropolitanos, a quem o artigo 144, § 8º., da Constituição Federal não outorga poder de polícia para investigar crimes nem para atuar no policiamento repressivo. Ora, no caso dos autos, houve uma desconfiança de que o réu pudesse ter algo ilícito consigo, pela forma como reagiu ao ver os guardas, esboçando uma tentativa de fuga.

Sem que houvesse a certeza visual da posse de drogas, realizou-se a abordagem do acusado, submetendo-os a revista pessoal, oportunidade em que se encontraram em uma sacola que ele portava as drogas.

De se frisar que a apreensão se deu em via pública, a alguma distância do Centro Temporário de Acolhimento, ou seja, o réu não ingressou nem tentou ingressar nas dependências do serviço municipal com os entorpecentes.

Tal diligência é ilícita, por manifesto desvio de função.

A Guarda Civil não tem competência e nem autoridade para realizar busca pessoal em via pública, porque desconfia da atitude de um passante.

Busca pessoal é ato de investigação policial, disciplinado nos artigos 240 e 244 do Código de Processo Penal, e como tal está reservado às polícias a quem a Constituição Federal outorgou tal competência.

Se a qualquer cidadão é outorgado o direito de prender indivíduo em situação de flagrância, parece igualmente evidente que somente as autoridades competentes é que podem submeter um suspeito a busca pessoal. Ninguém admitiria ser revistado por qualquer do povo, e aliás admitir-se tal possibilidade equivaleria a degenerar a autoridade estatal e a pôr em risco a própria convivência em sociedade.

Ora, para fins de busca pessoal, um guarda civil tem a mesma competência legal que um cidadão qualquer, ou seja, nenhuma.

Não se está aqui a tratar nem de situação de evidente flagrância (pois ninguém viu os réus manuseando drogas) e nem de mera revista preventiva em que, fortuitamente, encontrou-se algo ilícito. Houve a prática de ato típico de polícia (busca pessoal fundada em suspeita) por agente público absolutamente incompetente para tanto, desbordando das funções que a Constituição Federal permitiu às guardas municipais.

Nesse sentido, cito precedentes:

Por expressa previsão constitucional, às forças policiais civil e federal fora reservada atribuição para a investigação de fatos delituosos, ao passo que à guarda municipal não fora prevista qualquer atuação em matéria de segurança pública. E, enquanto agentes administrativos, regidos pelo princípio da legalidade, só podendo atuar aonde a lei autoriza, essa falta de previsão implica verdadeira vedação de agir.

Guardas civis municipais não têm, portanto, competência legal para desenvolver ação pertinente à segurança pública, como policiamento preventivo, atividade, repita-se à exaustão, por expressão previsão constitucional, exclusiva das forças policiais. Nos termos da redação do §8º do artigo 144 da Constituição da República, incumbe aos guardas municipais somente a proteção dos bens, serviços e instalações municipais, conforme dispuser a lei, enquanto que, segundo disposto no caput do artigo 144, a segurança pública deve ser exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo atribuição exclusiva das polícias federal, rodoviária federal, ferroviária federal, polícias civis, militares e dos corpos de bombeiros militares.

(...)

Se é evidente a invalidade do comportamento dos guardas civis que, em contrariedade à Constituição, estavam a investigar e à busca de ilícitos criminais, são ilícitas, por derivação, as provas obtidas. Isto porque tudo fora coligido como fruto de

diligência realizada por órgão administrativo sem atribuição constitucional e legal para a prática de atos concernentes à segurança pública. (TJSP - Apelação nº 0001468-60.2016.8.26.0544 - Franco da Rocha - rel. Márcio Bártoli - 1ª. Câmara Criminal - j. 23.04.2018)

Merece ainda seja trazido como fundamento o v. Acórdão proferido pelo E. Tribunal de Justiça deste Estado, na RevCrim 0034551-84.2015.8.26.0000 (6º Grupo Criminal, rel. Vico Mañas, j. 07.06.2007, M.V), pela riqueza de argumentos e citações colmatados, inclusive com menção a precedente do C. Órgão Especial do mesmo Tribunal, que declarou inconstitucional dispositivo de lei municipal que pretendeu conferir à Guarda Civil Metropolitana atribuições típicas de polícia:

Ora, o art. 144, § 8º, da Constituição Federal atribui aos guardas municipais a proteção dos bens, serviços e instalações municipais. Atividades de investigação e policiamento ostensivo, conforme expresso nos demais parágrafos do mesmo artigo, constituem função das polícias civil e militar.

Nem se diga que, regulamentando a norma constitucional, a Lei 13.022/14 prevê como "competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais", "colaborar, de forma integrada com os órgãos de segurança pública, em ações conjuntas que contribuam com a paz social", "encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante delito, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário" (art. 5º, IV e XIV). Parece claro que tais disposições não autorizam a guarda municipal a efetuar diligências para apurar suspeitas de tráfico, permanecendo tais atividades privativas da polícia.

Cumpra ainda observar que a Lei 13.022/14 é objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5156, em que se questiona a possibilidade de atribuir às guardas municipais funções de segurança pública. E, em seu parecer, o Procurador-geral da República opina que "não compete a guarda municipal o exercício, direto ou indireto, de atividades próprias à segurança (...). As guardas só podem existir se destinadas à proteção de bens, serviços e instalações do Município. Não lhes cabem, portanto, os serviços de polícia ostensiva, de preservação da ordem pública, de polícia judiciária e de apuração das infrações penais. Aliás, essas competências foram essencialmente atribuídas à Polícia Militar e à Polícia Civil, consoante prescrevem os §§ 4º e 5º, do susotranscrito art. 144 da Carta Federal".

Esse também o entendimento adotado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal ao declarar a inconstitucionalidade do inciso I do artigo 1º da Lei nº 13.866/04, do Município de São Paulo, que disciplina a atuação da Guarda Civil Metropolitana: "se, por um lado, a Constituição Federal abre possibilidade aos Municípios de constituírem 'guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei' (art. 144, § 8º - regra repetida pelo art. 147 da Constituição Estadual), por outro, atribui o exercício da segurança pública a outros órgãos, descritos no mesmo artigo, nos seus incisos. Esses órgãos são as chamadas polícias que, no âmbito estadual, são a polícia militar, que atua preventivamente, e a polícia civil, de caráter repressivo. Releva notar que a descrição do 'caput' do art. 144 não deixa dúvidas: a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Nesse diapasão, ao se examinar o inciso I do artigo 1º da legislação municipal, percebe-se nítido o conflito com o mandamento constitucional. Isso porque traz como atribuição da Guarda Civil Metropolitana o exercício de policiamento preventivo e comunitário, expressão que indica a atividade de segurança pública e que somente pode ser exercida pelos órgãos já mencionados. (...) são atividades, pois, típicas de segurança pública, que se inserem no âmbito exclusivo do Estado, com suas polícias. A limitação da competência das guardas municipais se dá, assim, pelo cotejo entre os parágrafos do art. 144 e também com o seu 'caput'" (Adinº 154.743-0/0-00, Rel. Des. Mauricio Ferreira Leite, j. em 10.12.2008).

(...)

Também merece destaque o parecer do d. Procurador de Justiça oficiante, Luiz Antonio Guimarães Marrey, para quem o limite constitucional de ação das guardas municipais está claramente estabelecido, ainda que o art. 144, § 8º, da CF faça parte do capítulo "Da Segurança Pública": "o exercício do poder de polícia

municipal, nas atividades que lhe são próprias, não se confunde com a atividade de polícia judiciária ou de manutenção da ordem pública, deferidas aos Estados e que não podem ser delegadas. Dessa forma é ilegítima a atividade de investigar e de fazer buscas pessoais ou em veículos por parte de integrantes da Guarda Municipal, em atividade estranha à sua atribuição constitucional. Aceitar-se conclusão contrária significaria admitir que cidadãos comuns devem suportar buscas feitas a esmo por funcionários públicos municipais que não exercem a função policial (...). Se há suspeita de crime, como regra, devem os guardas chamar a polícia e dar as informações pertinentes que permitam a ação policial. Claro que poderão agir quando houver flagrante delito visível, mas o farão na condição de pessoas do povo, como por exemplo um roubo à mão armada que esteja em curso ou em situação de flagrância ou mesmo o tráfico de drogas realizado de maneira explícita. No entanto, ninguém é obrigado a se submeter a revista feita por iniciativa de qualquer pessoa do povo". Em artigo, o ex-Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo também ponderou que, "quando a Guarda Municipal age escancaradamente como polícia, está aberta a porta para a repetição de episódios de violência e criminalidade. Não é incomum ver rondas ostensivas de guardas civis, imitando a polícia. Assim, é necessário que autoridades policiais, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário atuem para coibir a ilegalidade, reconduzindo a atividade das Guardas Municipais aos limites constitucionais e legais. O que não se pode aceitar é que, em nome da necessidade de segurança pública, o abuso e a ilegalidade sejam permitidos, por vezes com graves consequências. A lei autoriza o uso da força de maneira legítima e estrita, mas o Estado de Direito deve valer para todos, exigindo que a violência e a ilegalidade sejam coibidas e punidas, venham elas de criminosos comuns ou de agentes públicos (Folha de São Paulo, "Guarda Municipal não é polícia", publicado em 05.07.2016, disponível em <http://www1.folha.uol.com.br/opiniaio/2016/07/1788484-guarda-municipal-nao-epolicia.shtml>)"

No mesmo sentido (ilegalidade de revista pessoal por Guarda Civil diante de mera suspeita, sem certeza visual do delito, caso EM TUDO ANÁLOGO AO AQUI TRATADO), concluiu o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento (Resp nº 1977119/SP - Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz - 6a. Turma - j. 16/08/2022 - v.u.): RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ATUAÇÃO DAS GUARDAS MUNICIPAIS. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CLARA, DIRETA E IMEDIATA COM A TUTELA DOS BENS, SERVIÇOS E INSTALAÇÕES MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 157 E 244 DO CPP. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal de 1988 não atribui à guarda municipal atividades ostensivas típicas de polícia militar ou investigativas de polícia civil, como se fossem verdadeiras "polícias municipais", mas tão somente de proteção do patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações. A exclusão das guardas municipais do rol de órgãos encarregados de promover a segurança pública (incisos do art. 144 da Constituição) decorreu de opção expressa do legislador constituinte - apesar das investidas em contrário - por não incluir no texto constitucional nenhuma forma de polícia municipal.

2. Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil - em contrapartida à possibilidade de exercerem a força pública e o monopólio estatal da violência - estão sujeitas a rígido controle correcional externo do Ministério Público (art. 129, VII, CF) e do Poder Judiciário (respectivamente da Justiça Militar e da Justiça Estadual). Já as guardas municipais - apesar da sua relevância - não estão sujeitas a nenhum controle correcional externo do Ministério Público nem do Poder Judiciário. É de ser ver com espanto, em um Estado Democrático de Direito, uma força pública imune a tais formas de fiscalização, a corroborar, mais uma vez, a decisão conscientemente tomada pelo Poder Constituinte originário quando restringiu as balizas de atuação das guardas municipais à vigilância do patrimônio municipal.

3. Não é preciso ser dotado de grande criatividade para imaginar - em um país com suas conhecidas mazelas estruturais e culturais - o potencial caótico de se autorizar que cada um dos 5.570 municípios brasileiros tenha sua própria polícia, subordinada apenas ao comando do prefeito local e insubmissa a qualquer controle externo. Ora, se mesmo no modelo de policiamento sujeito a controle externo do Ministério Público e concentrado em apenas 26 estados e um Distrito Federal já se

encontram dificuldades de contenção e responsabilização por eventuais abusos na atividade policial, é fácil identificar o exponencial aumento de riscos e obstáculos à fiscalização caso se permita a organização de polícias locais nos 5.570 municípios brasileiros.

4. A exemplificar o patente desvirtuamento das guardas municipais na atualidade, cabe registrar que muitas delas estão alterando suas denominações para “Polícia Municipal”. Ademais, inúmeros municípios pelo país afora – alguns até mesmo de porte bastante diminuto – estão equipando as suas guardas com fuzis, equipamentos de uso bélico, de alto poder letal e de uso exclusivo das Forças Armadas.

5. A adequada interpretação do art. 244 do CPP é a de que a fundada suspeita de posse de corpo de delito é um requisito necessário, mas não suficiente, por si só, para autorizar a realização de busca pessoal, porque não é a qualquer cidadão que é dada a possibilidade de avaliar a presença dele; isto é, não é a todo indivíduo que cabe definir se, naquela oportunidade, a suspeita era fundada ou não e, por consequência, proceder a uma abordagem seguida de revista. Em outras palavras, mesmo se houver elementos concretos indicativos de fundada suspeita da posse de corpo de delito, a busca pessoal só será válida se realizada pelos agentes públicos com atribuição para tanto, a quem compete avaliar a presença de tais indícios e proceder à abordagem do suspeito.

6. Ao dispor no art. 301 do CPP que “qualquer do povo poderá [...] prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”, o legislador, tendo em conta o princípio da autodefesa da sociedade e a impossibilidade de que o Estado seja onipresente, contemplou apenas os flagrantes visíveis de plano, como, por exemplo, a situação de alguém que, no transporte público, flagra um indivíduo subtraindo sorrateiramente a carteira do bolso da calça de outrem e o detém. Diferente, porém, é a hipótese em que a situação de flagrante só é evidenciada após realizar atividades invasivas de polícia ostensiva ou investigativa como a busca pessoal ou domiciliar, uma vez que não é qualquer do povo que pode investigar, interrogar, abordar ou revistar seus semelhantes.

7. Da mesma forma que os guardas municipais não são equiparáveis a policiais, também não são cidadãos comuns. Trata-se de agentes públicos com atribuição sui generis de segurança, pois, embora não elencados no rol de incisos do art. 144, caput, da Constituição, estão inseridos § 8º de tal dispositivo; dentro, portanto, do Título V, Capítulo III, da Constituição, que trata da segurança pública em sentido lato. Assim, se por um lado não podem realizar tudo o que é autorizado às polícias, por outro lado também não estão plenamente reduzidos à mera condição de “qualquer do povo”; são servidores públicos dotados do importante poder-dever de proteger o patrimônio municipal, nele incluídos os seus bens, serviços e instalações.

8. É possível e recomendável, dessa forma, que exerçam a vigilância, por exemplo, de creches, escolas e postos de saúde municipais, de modo a garantir que não tenham sua estrutura física danificada ou subtraída por vândalos ou furtadores e, assim, permitir a continuidade da prestação do serviço público municipal correlato a tais instalações. Nessa esteira, podem realizar patrulhamento preventivo na cidade, mas sempre vinculados à finalidade específica de tutelar os bens, serviços e instalações municipais, e não de reprimir a criminalidade urbana ordinária, função esta cabível apenas às polícias, tal como ocorre, na maioria das vezes, com o tráfico de drogas.

9. Não é das guardas municipais, mas sim das polícias, como regra, a competência para patrulhar supostos pontos de tráfico de drogas, realizar abordagens e revistas em indivíduos suspeitos da prática de tal crime ou ainda investigar denúncias anônimas relacionadas ao tráfico e outros delitos cuja prática não atinja de maneira clara, direta e imediata os bens, serviços e instalações municipais. Poderão, todavia, realizar busca pessoal em situações absolutamente excepcionais – e por isso interpretadas restritivamente – nas quais se demonstre concretamente haver clara, direta e imediata relação de pertinência com a finalidade da corporação, isto é, quando se tratar de instrumento imprescindível para a tutela dos bens, serviços e instalações municipais. Vale dizer, só é possível que as guardas municipais realizem excepcionalmente busca pessoal se houver, além de justa

causa para a medida (fundada suspeita de posse de corpo de delito), relação clara, direta e imediata com a necessidade de proteger a integridade dos bens e instalações ou assegurar a adequada execução dos serviços municipais, o que não se confunde com permissão para realizarem atividades ostensivas ou investigativas típicas das polícias militar e civil para combate da criminalidade urbana ordinária.

10. Na hipótese dos autos, os guardas municipais estavam em patrulhamento quando depararam com o recorrente sentado na calçada, o qual, ao avistar a viatura, levantou-se e colocou uma sacola plástica na cintura. Por desconfiar de tal conduta, decidiram abordá-lo e, depois de revista pessoal, encontraram no referido recipiente certa quantidade de drogas que ensejou a prisão em flagrante delito.

11. Ainda que eventualmente se considerasse provável que a sacola ocultada pelo réu contivesse objetos ilícitos, não estavam os guardas municipais autorizados, naquela situação, a avaliar a presença da fundada suspeita e efetuar a busca pessoal no acusado. Caberia aos agentes municipais, apenas, naquele contexto totalmente alheio às suas atribuições, acionar os órgãos policiais para que realizassem a abordagem e revista do suspeito, o que, por não haver sido feito, macula a validade da diligência por violação do art. 244 do CPP e, por conseguinte, das provas colhidas em decorrência dela, nos termos do art. 157 do CPP, também contrariado na hipótese.

12. Recurso especial provido.

Destarte, ante a desconfiança que a atitude do réu causou aos Guardas Civis, cabia-lhes comunicar tal fato a autoridades policiais para que estas, legitimadas a tanto, realizassem a diligência tipicamente investigativa de busca pessoal. Praticado o ato por agente público a quem o ordenamento jurídico não outorga competência para tanto, não há como admitir a licitude da apreensão dos entorpecentes.

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal movida pela Justiça Pública e ABSOLVO o réu TIAGO DOS SANTOS PEREIRA da imputação irrogada pela denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Determino, ao trânsito em julgado, a destruição das restantes amostras dos entorpecentes apreendidos.

O dinheiro apreendido, localizado juntamente com entorpecentes e à sua mercancia relacionado, será perdido em favor da União, expedindo-se o necessário para oportuna transferência ao FUNAD.

Publicada em audiência.

As partes saem intimadas.

São Paulo, 26 de setembro de 2022.